

1、法とは何か？

(1) 法…強制力のある規範 例：法律、条例、校則 =守らなくてはならない決まり

①法の存在理由…「社会あるところに法あり」

→「やられたらやり返す」では、紛争が絶えず、強者が勝つだけ

⇒復讐権から自力救済の禁止、国家の刑罰権の独占(国家の強制力)へ

ア、自力救済の禁止…私人が法の定める手続によらずに自己の権利を実現することを禁止する原則

例：お金を貸したけど返してくれない。…家に押し入って、有り金ぶんどろう！！→NG

→実力行使は、お金のある方、力のある方が勝ってしまう。 例：警備員を雇う、暴力団を雇う

⇒公平な裁判により、国家が権利を確定し、権利を実現する。

イ、国家の刑罰権の独占…私的制裁を許すと法秩序が保てなくなる→社会・国家の秩序を守る

→刑罰は受ける人に重大な不利益を及ぼす＝冤罪の場合、人権侵害になるので慎重になる必要

→報復や被害者救済のためだけではない。(秩序維持＝再犯の防止、反省の程度)

(2) 法の目的

①正義を守るため…人間が法を作る以上、正義に適わないものあり

→議会で話し合って正しいものに変えていく必要

ア、正義…何が正義か不明確→目的や判断の基準になりえない可能性⇒正しさの基準とは？

・形式的正義…「等しきものは等しく、等しからざるものは等しからざるように取り扱え」

・実質的正義…

↓	{	交換的正義＝並列個人間の利得と損失の調整に関する交換関係における正義
		例：売買における目的物と対価、労働と賃金、損害と賠償(give and take)
		配分的正義＝社会成員間の利益と負担の割り当てに関する配分関係における正義
		例：収入に応じた課税、困窮度に応じた扶助、達成した仕事に応じた俸給
		(能力や功績に応じた分配)

・手続的正義…実質的正義の基準について一致がない場合に、一定の手続を経て出された結論を正義にかなうものと見なすという考え方(一定の手続を経ていない限り不正義とみなす考え方)

⇒立場の相違を超えて「公平」に考えたか否かがポイント(当事者の対等化と公正な機会の保障、第三者の公平性・中立性、理由づけられた議論と決定)

イ、法と正義

・法実証主義…正当な権限をもつ機関が所定の手続に則って制定した法律は、その道徳的な内容如何を問わず、法的効力をもち、人々を拘束

⇒人間の作った実定法だけが法である。＝「悪法もまた法なり」

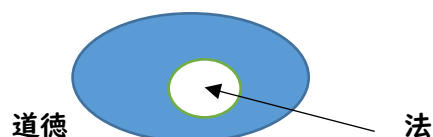
・自然法主義…人間の作った実定法の他に、効力・拘束力を基礎づけその正・不正を識別する自然法が存在→神の意志、人間の理性や本性等に基づき、人間の意志によって左右できない。

⇒道徳的な内容の正・不正に依存、自然法に反する実定法は原則として法的効力をもたず、人々はそれに従う義務もない。＝「悪法は法にあらず」

②秩序を守るため

ア、法の外面性と道徳の内面性

イ、法は最小限の道徳



※責任から見た法と道德の関係…道德には情があるが法には情がない

→道德的な責任は、法的な責任だけでは済まされない。 例：道義的責任

※法と道德の関係＝
密接：人を殺してはいけない。
無関係：右側通行
対立：ナチスの処刑、治安維持法

(3) 法の歴史

※古くは、ローマ法とゲルマン法に由来。

→ローマ法は、万民法主義で、どこでも通用する法を模索

→ゲルマン法は、部族主義で、その部族にのみ通用する慣習法を重要視

①大陸法…制定法主義＝国会が法を作る。判例でそれを補充する。

②英米法…判例法主義＝裁判官が法を作る。多数の判例の集積が法を形成する。

比較	規範面	制度面	技術面	主体面	司法への国民参加
大陸法	成文法主義	行政裁判所	体系思考	職業裁判官制	参審制
英米法	判例法主義	司法権の優越	問題思考	法曹一元制	陪審制

→日本は、ドイツ・フランスの法(大陸法)を輸入し、戦後、アメリカの考え方(英米法)が導入された。

※ドイツ・フランスの考え方が強い法…民法、商法、民事訴訟法、刑法

※アメリカの考え方が強い法…憲法、刑事訴訟法、独占禁止法、労働組合法、金融商品取引法

③法と文化…国によって大きく異なる。→海外旅行や国際取引で注意！

例：イスラム金融…利子を取ることを禁止

イスラムの一夫多妻制…4人まで正妻を持つこと可能

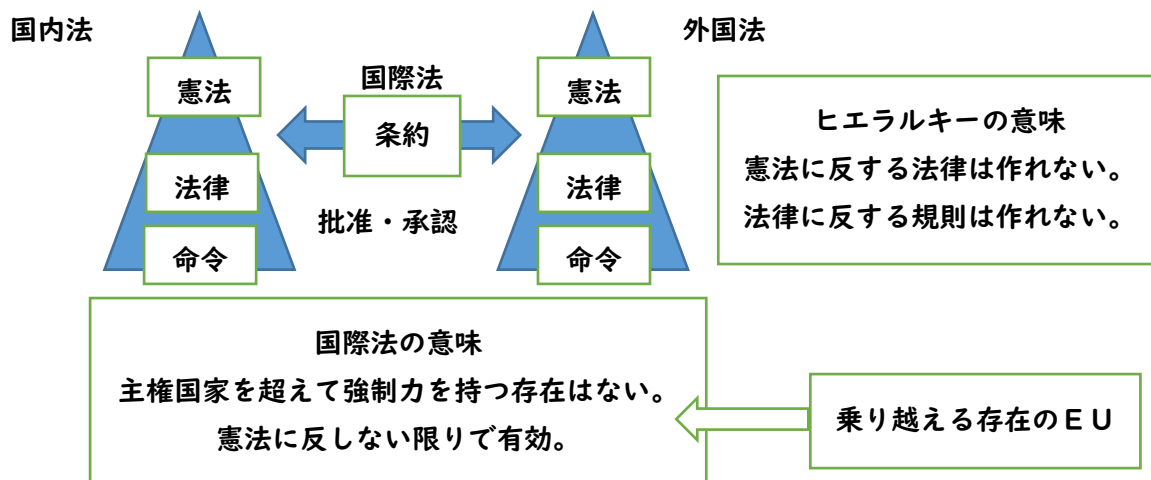
オーストラリア・マレーシアにおける大麻所持の重罰 例：メルボルン事件

3、法の体系

(1) 法学の分類

- | | | |
|----------------------|---|---|
| ①実定法学
例：民事法学、刑事法学 | { | ア、解釈論・・・法文の解釈
イ、立法論・・・法の改正や新たに法を作ること |
| ②基礎法学
例：法哲学、法制史 | { | |

(2) 法のヒエラルキー構造



①国内法…国内を規律する法

→国内法と国際法の序列…日本：憲法＞条約＞法律

Cf. 条約＞憲法＞法律（オランダ）、憲法＞条約＝法律（アメリカ）

②国際法…国際社会のシステム(国際社会の組織化)に基づく国家の権利義務

ア、条約（国家により文書の形式で締結され、国際法によって規律される国際的な合意）

※条約の締結手続…条約法に関するウィーン条約（条約法条約、1969年）

⇒留保制度…条約当事者になる際に、条約の特定の規定の法的効果を排除または変更することを宣言（多数国間条約の当事国数を確保するために認められていた制度）

イ、慣習国際法（国家慣行と法的信念の要件により、全ての国家を拘束するもの）

※不文法なので、規則の存否や内容が不明確なことが多い 例：武力行為禁止義務

	条約	慣習国際法
メリット	内容が比較的明確	全ての国を拘束
デメリット	非締約国は不拘束	不文法ゆえに内容が不明確なことが多い

※戦争を前提とする国際法は、戦時国際法と平時国際法に分類→第二次世界大戦後は、武力行使禁止原則が確立して一元的な国際法へ

例：紛争の解決

ア、国内法…裁判所による解決

イ、国際法…平和的な手段としての外交交渉、強制的な手段としての報復（経済援助の打ち切り等）・武力行使を伴わない復讐（相手国国民の財産の収用等）→第三者の介入としての国際裁判(国際司法裁判所)、安全保障理事会による国連の関与

※国際裁判は、強制的管轄権(裁判をする権限)がなく、強制執行の仕組みも不十分(自発的履行の必要)

（３）法の種類

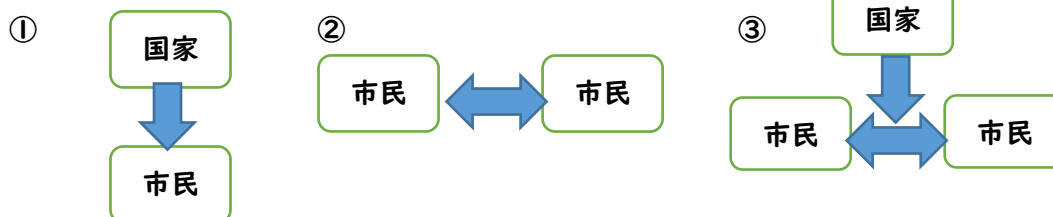
＜公法と私法＞←当事者に注目

①公法…国家と国民の関係を規律する法 例：刑法 ※力関係があることを前提とする。

②私法…市民と市民の関係を規律する法 例：民法 ※平等であることを前提とする。

③社会法…市民同士でうまくやってくれるように国家が調整する法 例：労働法

※平等であることを前提とするが、実際は異なる場合。



＜民事法と刑事法＞←責任に注目 例：交通事故

①民事法…私人間の利害調整ルール 例：治療費や慰謝料などの損害賠償

②刑事法…国家の刑罰ルール 例：危険運転致死傷罪

＜強行法と任意法＞←効力の強さに注目

①強行法…当事者の意思いかんにかかわらず当然に適用されるもの 例：刑法

②任意法…当事者の意思によってその適用を排除することを許すもの。 例：民法の物権、債権

(4) 法の機能

- ①社会統制…犯罪などの抑制・処罰など、一定の行動様式を取ることを何らかのサンクションによって確保＝社会秩序を維持
- ②活動促進…人々が準拠すべき指針や枠組みを提示し、その自主的な活動を予測可能で安全確実にする
- ③紛争解決…人々の間に生じる対立や紛争を調整し解決する仕組みを提供
- ④資源配分…限られた社会的資源・財・サービスの配分を行ったり、一定の社会経済政策を遂行（政策の実施に当たる機関の組織・権限や活動基準・計画・手続）

(5) 法的な考え方：要件と効果…一定の条件(要件)を満たすと、一定の効力(効果)を生じさせる。

- ①法律要件：権利義務関係等の変動を生じさせるために必要な一定の事実
- ②法律効果：権利義務関係の変動を生じさせること

例：人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。(刑法199条)

ア、法律要件：人を殺した者は、

イ、法律効果：死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

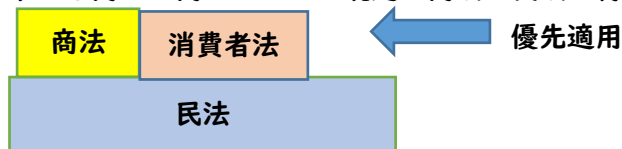
例：故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法709条)

ア、法律要件：故意又は過失によって、他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、

イ、法律効果：これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(6) 法律の優劣関係

- ①一般法と特別法＝「特別法は一般法に優先する」例：民法と商法、民法と消費者契約法、
民法：人同士のこと一般を規定 商法は民法に優先する。 民法と借地借家法
商法：人の中でも商人や商いについて規定 商法は民法の特別法である。



- ②後法は前法に優先する＝後からできた法律の法を優先して解釈する。

(7) 重要な用語

①善意と悪意

ア、善意：×よいつもりで→○知らない

道徳的意味

法的意味

A 過失なし＝善意無過失

B 軽過失あり＝善意有過失

C 重過失あり…善意重過失

イ、悪意：×悪いつもりで→○知っている

②推定と「みなす」

ア、推定：ある事実又は法律関係が明瞭でない場合に、法令が通常予想される事態を前提として、一応、その状態にあるものと判断をして、その取扱いを定める場合 ※反対の証拠がある場合には、推定は覆される。

例：民法772条「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」

イ、みなす：ある事柄とある性質を異にする事柄について、一定の法律関係において、同一視し、それについての法的効果をそれとは異なる事柄に及ぼす場合

例：民法753条「未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。」

4、法解釈…条文解釈技法

(1) 立法の存在意義

→多くの場合：法律に明記

→法律に明記していない場合：どうしてそのような法律が作られたのか、なぜ法律はそのような制度を設けたのかを考慮する必要：立法趣旨と制度趣旨

(2) 解釈の在り方…法律の意味は一義的に定まるわけではない。

①立法者意思説…法は立法者が作ったものであるという考え方

→立法者が考えていないと、法はないことになる。

→時代の変化により妥当しなくなると、あるべき法に反する法が存在することになる。

②法律意思説(通説)…法律は成長していくものであるという考え方

→当然に内容が変わるという考え方

→判例により内容が改正されるという考え方

ア、先行的価値判断…結果の妥当性、実質的根拠づけ「結果が妥当である。」

→当事者の利益衡量、社会全体への影響、政策的な解決 例：取引安全

イ、理論的根拠づけ…どうしてそうなのかという理屈づけ 例：対抗問題、登記の公信力の問題

ウ、条文上の根拠づけ…制定法の条文から導かれたかのような装い 例：類推・縮小・拡大等の解釈

※条文の解釈の名を借りた実質的法創造の場合…類推解釈、制限解釈(善意→善意無過失)、信義則

(3) 解釈技法 例：「オートバイその他の車両の乗り入れを禁止する。」

①文理解釈…書いてある通りにそのまま解釈すること

※自動車は、車両であるので、乗り入れが禁止される。

②論理解釈

ア、拡張解釈：法文中の意味を通常の意味以上に拡張して解釈

※この禁止は、公園を利用する他の人の迷惑・危険となる行為を制限するものであるから、オートバイを引いて入ることも「乗り入れ」に含まれ、禁止される。

イ、縮小解釈：法文の言葉を通常の意味するところよりも狭く解釈

※障害者や高齢者が使用する電動車いすは、車両に該当するが、その乗り入れを禁止することは、これらの人の公園の利用を困難とするので、車両には含まれない。

ウ、類推解釈：直接の規定がない場合に、その規定と同じ趣旨の規定が他方にもあると考えて、それを準用する解釈

※馬については定めがないが、卵まで乗り入れることも車両の乗り入れに準じて考えることができるので、馬の乗り入れも禁止される。

エ、反対解釈：法文に書いてあるところを基として、他の場合はその反対であると推定し、逆の効果が生ずる趣旨の規定をも含んでいると解釈

※一輪車は、車両ではないので、乗り入れることは許される。

オ、勿論解釈：法令の規定の目的・趣旨などから見て、他の場合にはそのような規定がなくても、それと同じ規定があると解することが条理上当然と考えられる場合に取られる解釈

※ブルドーザーは車両ではないが、当然乗り入れが禁止される。

※解釈にあたっての考量要素

{	・必要性和許容性
	・結果の妥当性(価値判断)と法的安定性(論理性)